

※ 들어가며 ※

- 먼저, 무더운 여름 불규칙한 날씨와 싸우며 2차 시험을 치루신 수험생 여러분들, 고생 많으셨습니다. 노력하신 만큼 좋은 결실이 있으시길 바랍니다.
- 본 자료는 강사의 개인적인 사건이며 출제자의 의도, 논점과 다소 다를 여지는 있음을 참고하시기 바랍니다.

※ 총 평 ※

- 이번 2차 민소 문제는 기본서의 전 범위에 걸쳐 고루 출제하려는 경향이 두드러졌으며 중요한 논점 위주로, 기본서의 내용을 정확히 이해하고 있는지에 출제의 주안점을 둔 것으로 판단됩니다. 나아가 이송, 항고절차 등을 출제함으로서 기본서를 꼼꼼히 정리하지 않고 사례집 위주로 준비한 수험생과 점수의 차별성을 목적에 둔 것으로 보입니다. 다시 정리하면,

- ★ 전반적으로 A급 이상의 문제로 무난히 출제되었습니다.
- ★ 동차생 분들도 포기하지 않고 끝까지 최선을 다 하신 분들은 생각보다 좋은 점수를 기대할 수 있지 않을까 조심스럽게 예상해 봅니다.
- ★ A-2(이송) 논점은 2011년 판시를 기본으로 다소 불의타로 느끼셨을 듯하나 ‘이송에 관한 사유 등 일반론’, ‘즉시항고, 재항고 등 불복방법의 소개’ 등의 배점을 충분히 챙기셨다면 상대적 평가인 시험 특성상 무난한 점수를 받으실 것으로 생각됩니다.

- 무난한 문제가 출제될 경우 ‘정확한 논점의 파악’, ‘문제점(논의의 배경, 논점의 필요성), ‘判例의 정확한 소개’, ‘충실한 검토’ 등에서 생각 이상의 점수 차이가 날 수 있습니다.

※문항 별 시범답안 - key-word※

□ 간략히 key-word 위주로 작성해 보았습니다. 참고하세요.

[A-1]

I. 설문(1)의 해결 - ① 선정의 적법여부

1. 문제점

- 먼저, 각 선정이 적법한지 문제됨

2. 의의 및 취지

- 53조, 소송 진행 번잡방지, 변론 복잡 방지

3. 요건

- 다, 이, 선, 특¹⁾
- 설문은 다른 요건은 문제되지 않으나 “공동의 법률상 이해관계”가 있는지 문제됨

4. 견해의 대립

- 모든 공동소송 可 견해, only 필·공만 인정하는 견해, 필·공 + 65조 전문(주요 공격 방어방법 공통인 경우, 通說)

5. 判例의 태도

- 원칙 : 通說
- 예외 : 주요 공격 방어방법 공통인 경우 65조 후문 확대 인정(각 임차인들이 진정한 임대인임을 공통으로 주장하며 제기한 임차보증금 반환청구 判 - 각 임차인들은 65조 후문의 관계(동종)일 뿐이나 ‘누가 진정한 임대인인가’라는 주된 공격방법을 공통으로 함)

6. 검토 및 설문의 경우

- 65조 전문까지 인정하는 견해 타당(∵ 변론복잡방지 취지상, 주요공격방법 공통)
- 설문의 경우 불법행위 공동피해자로 제65조 전문 후단의 관계, 선정 적법함.

1) 공동소송을 할 다수자가 있을 것, 공동의 법률상 이해관계가 있을 것, 공동의 이해관계가 있는 자 중에서 선정할 것, 특정의 소송에 관하여 선정할 것

II. 설문(1)의 해결 - ②각 소송수행 형태 및 심판방식

1. 문제점

- 먼저, 각 선정당사자들의 소송수행의 형태가 문제됨. 선정자들이 필수적 공동소송인의 관계인 경우 선정당사자들의 관계는 모두 필수적 공동소송인의 관계가 되나, 설문의 경우 선정자들은 통상공동소송인에 불과하여 검토가 필요함.
- 나아가, 丙의 불출석의 효과로 자백간주 또는 취하간주의 효과²⁾가 모두에게 미칠 수 있는지 그 심판의 방식이 문제됨.

2. 공동 선정당사자(乙, 丙)의 경우

(1) 소송관계

- 선정자들의 소송 수행권을 '합유적' 행사  고유필(通說, 判例)³⁾
- 선정자들의 실체법상 관리처분권을 공동으로 행사하므로 타당

(2) 심판방식(제67조 내지 제69조) : 연, 건, 자, 진, 판⁴⁾

- 제54조에 따라 공동선정당사자 중 1인의 자격함결인 경우를 제외하고서는 고유필수적 공동소송인의 심판방식 적용(제67조 ~ 제69조)
- 특히, 제67조제1항에 따라 소송자료가 통일되어 유리한 소송행위는 단독으로 하여도 모두에게 효력이 있음
- 한 사람이 주장사실을 다투면 전원이 다투는 것, 한 사람이 기일에 출석하여 변론하였으면, 다른 공동소송인이 결석하여도 기일불출석의 효과(자백간주, 취하간주)가 발생하지 않으며, 한 사람이 상소기간 등을 지켰으면 다른 사람이 지키지 못하여도 무방

3. 丁 및 단독 선정당사자(甲)의 경우

(1) 각 소송관계

- 통상공동소송 only
- 甲의 경우 선정자들의 소송수행권을 각자 행사할 뿐이므로 타당

(2) 심판방식(제66조) : 건, 자, 진, 당, 판⁵⁾

- 소송요건의 개별적 조사, 소송자료의 독립(주장, 증거) - 단 변론의 전취지로 사용 可, 소송 진행의 독립, 당사자지위의 독립성, 심판의 독립(변론의 분리·일부판결 可, 승패가 일률적 x)
- 따라서 출석의 효과는 각자 받음

2) 불출석으로 발생할 수 있는 효과를 구체적으로 언급해 주면 좋겠습니다.

3) 단순히 '필수적 공동소송인의 관계'인지만으로는 다소 부족합니다. 유사필의 경우 기일출석의 효과는 제67조 제1항이 배제되어 각자 효과를 받는다는 견해(이)가 있기 때문입니다.

4) 연합관계, 소송요건의 개별적 조사, 소송자료의 통일, 소송진행의 통일, 판결의 통일

5)

4. 설문(1)의 해결

- 공동 선정당사자인 乙, 丙의 소송수행의 결과는 제66조에 따라 甲 및 丁에게는 미치지 않음
- 丙만의 불출석으로 자백간주 또는 취하간주의 효과가 발생할 수 있는지 문제되나 乙, 丙의 관계는 고유필수적 공동소송이므로 乙이 출석한 경우 제67조제1항에 따라 출석의 효과를 함께 받으므로 불출석으로 취급되지 않아 자백간주, 취하간주 등의 효과가 발생하지 않음

II. 설문(2)의 해결 - 선정자의 지위, 중복된 소제기 금지(제259조)

1. 문제점

- 소송계속 후에 선정시 선정자는 당연히 소송에서 탈퇴(제53조제2항), 이때 선정자가 소송수행권을 상실하는지 문제됨.
- 나아가 당사자적격 흠결여부와 별개로 중복된 소제기 금지에 해당하는지 문제됨.

2. 선정자의 지위 - 당사자적격 흠결인지⁶⁾

(1) 견해의 대립

- 적격유지설(이 :: 선정자 보호차원) : 선정자 당사자적격 유지(:: 선정자의 별소제기시 중복제소로 봄은 당사자적격 인정 전제임, 94조 경정권 유추 실익 有)
- 적격상실설(多) : 선정자 당사자적격 상실[:: 선정당사자는 ‘당사자’ ㄹ 선정자는 당사자적격 상실, 모순 저촉 가능하여 우선적으로 중복제소 적용 only, 선정취소 ㄴ(but 소급되지는 x)]

(2) 검토 및 설문의 경우

- 적격유지설은 선정자의 별소제기시 중복소송이라 볼 수 있으려면 소송수행권이 있어야 한다고 보나, 후소가 중복소송이 되는지 여부는 별개의 문제이므로 논리 필연적이지 않음.
- 제53조제2항의 조문해석에 충실한 적격상실설이 타당.

3. 중복된 소제기의 금지(제259조)

(1) 의의 및 취지

- 259조 / 판결 모순 저촉 방지, 소송경제

(2) 요건 및 효과

- 당사자동일, 소송물동일, 전소 계속 중 후소 제기
- 직권조사사항으로 부적법 각하
- 설문은 다른 요건은 문제되지 않으나 ‘당사자 동일’이 문제됨.

(3) 당사자 동일

- 당사자 동일0 : 원고 피고 反 ㄹ 해당 可
- 당사자 동일x
 - 원칙 : 중복제소x
 - 예외 : 기관력의 주관적 범위의 확장[변론종결후 승계인(218①), 선정당사자 ㄹ 선정

6) 이시윤 교수님(적격유지설)은 선정자의 별소제기시 중복소송으로 보기 위해서는 선정자의 당사자적격이 유지되어야 한다고 보시므로 별소의 적법여부와 관련 있는 논점으로 보입니다.

자(후소)(218③), 채권자대위소송의 경우]

(4) 설문의 경우

- 설문은 제3자의 소송담당의 경우로 선정자는 제218조제3항에 따라 기판력을 받으므로 동일한 당사자
- 따라서, 중복된 소제기에 해당. 별소는 부적법

4. 설문(2)의 해결

- A의 별소는 중복된 소제기로 부적법

[A-2]

I. 설문(1)의 해결 - 심급관할 위반 이송결정의 적법여부

1. 문제점

- 설문의 경우 관할위반의 이송(제34조제1항) 또는 재량이송(제35조)이 가능한지, 특히 전속관할인 심급관할 위반의 이송이 아닌지 判例의 태도를 중심으로 검토가 필요함.

2. 이송의 의의 및 취지

- 계속된 소송을 재판에 의해 이전시키는 것 / 시효중단, 제척기간 준수 이익보호, 소송경제

3. 이송의 원인 및 효과

(1) 관할위반에 의한 이송(제34조제1항)

- 관할이 없는 경우, 결정(직권)

(2) 심판의 편의에 의한 이송(재량이송, 제35조)

- 사유 : 현저한 손해(사익), 지연(공익)
- 방식 : 신청 또는 직권
- 예외 : 전속관할에 속하는 사건은 이송할 수 없음.

(3) 반소제기에 의한 이송(제269조제2항)

- 반소가 합의부 관할인 경우 직권 또는 신청에 따라 이송(반소피고의 합의부 이익보호)
- 요건 : 반소가 적법하게 제기, 반소가 지방법원 합의부 관할, 본소가 지방법원 단독판사의 전속관할이 아닐 것
- 예외(대판 1992. 5. 12. 92다2066) : 다만, 지방법원 본원 합의부가 지방법원 단독판사의 판결에 대한 항소사건을 제2심(항소심)으로 심판하는 도중에 합의부 관할에 속하는 반소 등이 추가된 경우에도 심급관할은 제1심 법원의 존재에 의하여 결정되는 전속관할 이어서 이미 정하여진 항소심의 관할에는 영향이 없음.

(4) 이송의 효과 : 구속력(제38조), 소송계속의 이전

4. 判例의 태도 (2011. 7.14. 자 2011그65 결정, 채무부존재확인)

대법원은 설문과 유사한 사안에서 “심급관할은 제1심법원의 존재에 따라 그에 대응하여 결정되는 전속관할”이며 “지방법원 합의부가 지방법원 단독판사의 판결에 대한 항소사건을 제2심으로 심판하는 도중에 지방법원 합의부의 관할에 속하는 반소가 제기되었다고 하더라도 이미 정하여진 항소심의 관할에는 영향이 없으며”⁷⁾ “따라서 이 사건 소송의 항소심은 원심법원의 관할에 속할 뿐만 아니라, 원심이 이유에서 함께 들고 있는 민사소송법 제35조는 전속관할인 심급관할에는 적용되지 않아 손해나 지연을 피하기 위한 이송의 여지도 없으므로 원심의 이 사건 결정은 어느 모로 보나 위법하다.”고 판시하였다.

5. 설문(1)의 해결

- (1) 설문의 경우 제1심 법원은 법 제18조에 따라 불법행위지에 근거한 토지관할이 인정되거나 최소한 피고가 관할위반의 항변을 하지 않고 본안에 관하여 변론한 것으로 보여 법 제30조에 따라 변론관할이 인정
- (2) 심급관할은 제1심법원의 존재에 따라 대응하여 결정되는 전속관할로서 이 사건 항소심인 지방법원 합의부(항소부)는 이미 정해진 적법한 심급관할임.
- (3) 따라서 반소제기에 의한 이송(제269조제2항)도 불가하여 관할위반에 따른 이송이 안되며, 법 제35조는 전속관할인 심급관할에는 적용되지 않아 본조에 따른 이송의 여지도 없음. 결국 법원의 이송결정은 위법함.

II. 설문(2)의 해결 - 이송결정에 대한 당사자의 불복절차

1. 이송결정에 대한 불복 가부

- 이송결정과 이송신청의 기각결정에 대하여는 즉시항고 할 수 있음(제39조).
- 여기에는 제34조제1항에 규정된 직권에 의한 이송결정과 제34조 제2항 및 제35조에 규정된 직권 또는 당사자의 신청에 의한 이송결정이 있으며 본소와 반소를 합의부에 이송한 경우에도 불복 가능(제34조제2항, 제3항 참조)
- 설문의 경우 甲은 법원의 이송결정에 대해 불복할 수 있음. 단, 불복의 형식이 즉시항고인지, 재항고인지 문제됨.

2. 항고의 종류 및 설문의 경우

(1) 항고의 종류

- 항고는 판결 이외의 재판인 결정, 명령에 대한 독립의 간이한 상고
- 통상항고(항고기간 제한이 없음), 즉시항고(1주일 불변기간, 제444조)
- 재항고(제442조) : 항고법원·고등법원 또는 항소법원의 결정 및 명령에 대한 항고

7) 대법원 1992. 5. 12. 선고 92다2066 판결

- 특별항고(불복할 수 없는 결정, 명령에 대하여 비상구제책으로 대법원에 직소하는 항고)

(2) 설문의 경우

- 항소법원의 결정에 대한 불복⁸⁾이므로 제442조에 따라 **재항고임**
- 대법원도 “제442조의 규정에 비추어 볼 때 항소법원의 결정에 대하여는 대법원에 재항고하는 방법으로 다투어야만”한다고 판시(대법원 2008. 5. 2. 자 2008마427 결정)

3. 재항고 절차

- 상고규정 준용(제443조제2항, 규칙 137조제2항)
- 기간 : 재항고가 통상항고인가 즉시항고인가 항고제기 기간과 관련하여 문제되는바 재항고의 대상이 되는 재판의 내용에 따라 판단. 그 재판의 내용이 즉시항고를 할 수 있는 것이라면 재항고는 즉시항고임. 설문은 제39조에 따라 즉시항고를 할 수 있는 것이므로 원재판을 고지한 날로부터 1주간의 불변기간(제444조)
- 재항고장은 원심법원에 제출(제425조, 제397조)
- 즉시항고의 경우에만 재항고이유서의 제출이 강제된다는 견해가 있으나⁹⁾ 즉시항고이든 통상항고이든 구별할 것이 아니며 그것이 현재 실무운영임.
- 독립된 서면에 의해야 함. 다른 서면을 원용할 수 없음.
- 법률심이므로 새로운 증거는 참작할 수 없음.

[B-1]

I. 설문(1)의 해결 - ①증서진부확인 소의 대상적격

1. 문제점

- 매매계약서, 영수증 진부확인 소는 사실관계의 확인을 구하는 소인바본 소가 제250조의 증서진부확인 소에 해당하여 적법한지, 특히 대상적격이 있는지 문제되며,
- 나아가 서면에 의해 증명되어야 할 법률관계에 관한 별소가 제기된 경우 진부확인 소의 확인의 이익이 없는지 判例의 검토가 필요.

2. 확인 소 일반론

(1) 의의 및 취지

- 현재의 권리·법률관계에 관하여 확인의 이익이 있는 경우를 그 대상으로 하는 소
- 제한적으로 소의 이익을 인정할 필요

(2) 요건 및 법원의 조치

- ①대상적격(청구적격)과 ②확인 이익이 있어야 함.
- 확인의 이익 등이 없는 경우 이는 소송물에 대한 소의이익이라는 요건의 문제로 직권조사사항이며 본 요건의 흠결이 있는 경우에는 법원은 부적법 각하(通. 判)

8) 지방법원본원합의부가 제2심으로서 최초로 한 결정, 명령 포함

9) 호문혁 등

- 설문의 경우 법률관계가 아닌 사실관계에 대한 확인을 구하는 것으로 대상적격 관련 증서진부확인 소(제250조)의 검토가 필요함.

3. 증서진부확인의 소(제250조)

(1) 의의 및 취지

- 제250조는 예외적으로 사실관계의 확인을 구할 수 있는 확인의 소를 허용
- 분쟁 그 자체가 해결되거나 적어도 분쟁 자체의 해결에 크게 도움

(2) 요건

- ‘법률관계’를 증명하기 위한 문서만을 그 대상으로 하며, ‘법률관계 문서’는 그 내용에 의해 ‘직접적’으로 현재의 법률관계의 존재가 증명될 수 있는 경우를 말하는 것으로써 처분문서인 경우가 원칙이나, 반드시 이에 한하지는 않으며 단순한 보고서나 사실문서는 그 대상으로 삼을 수 없음. 判例는 대차대조표나 회사결산보고서는 사실관계의 보고서에 지나지 않는다 하여 진부확인의 대상이 아니라고 함.¹⁰⁾
- 또한 확인 대상이 되는 진정여부란 형식적 진정성립 즉 서면이 그 작성명의자에 의하여 작성된 것인가 아니면 위조, 변조되었는가를 말하는 것이지, 문서의 내용이 객관적 진실에 합치하는지 여부를 말하는 것은 아님.¹¹⁾

(3) 영수증의 경우 - 判例의 태도¹²⁾

- 대법원은 설문과 유사한 사안에서 “증서의 진정 여부를 확인하는 소의 대상이 되는 서면은 ‘직접 법률관계를 증명하는 서면에 한하고, ‘법률관계를 증명하는 서면’이란 그 기재 내용으로부터 직접 일정한 현재의 법률관계의 존부가 증명될 수 있는 서면을 말하므로 임대차계약금으로 일정한 금원을 받았음을 증명하기 위하여 작성된 영수증은 특별한 사정이 없는 한 임대차 등 법률관계의 성립 내지 존부를 직접 증명하는 서면이 아니므로 증서의 진정 여부를 확인하는 소의 대상이 될 수 없다.”고 판시한바 있음¹³⁾.

4. 검토 및 설문의 경우

- 증서의 진정 여부를 확인하는 소가 적법하기 위해서는 그 서면에 대한 진정 여부의 확인을 구할 이익이 있어야 하고 이를 통해 법률관계에 관한 분쟁 그 자체가 해결되거나 적어도 분쟁 자체의 해결에 크게 도움이 된다는 데 있으므로¹⁴⁾ 判例 타당함.
- 설문에서 매매계약서는 처분문서로써 제250조에서 말하는 법률관계를 표상하는 문서이므로 대상적격이 있으나,

10) 대법 1967. 3. 21, 66다2154판결 등

11) 대법 2001. 12. 14, 2001다53714판결 참조

12) 단순히 ‘보고문서’라는 이유로 배척하시는 것은 판결의 취지를 이해하지 못하고 있다는 인상을 줄 수 있습니다. 사안의 ‘영수증’이 단순한 보고문서인지 단정할 수 없고, 判例가 본 사안에서 단순한 보고문서라는 이유로 배척하고 있지 않기 때문입니다.

13) 대법원 2007. 6. 14. 선고 2005다29290, 29306 판결

14) 判例가 판시하고 있는 내용이기도 합니다.

- 영수증 자체는 직접 표상하는 문서로 보기 어려워 이를 증서진부확인의 소의 대상으로 삼는 것이 타당하지 않으므로 영수증 진부확인의 소는 부적법

II. 설문(1)의 해결 - ②증서진부확인의 소의 확인의 이익

1. 문제점

- 매매계약서 진부확인의 경우 대상적격은 있으나 서면에 의해 증명되어야 할 법률관계에 관한 소가 후에 제기된 경우 확인의 이익이 없는지 문제됨.

2. 判例의 태도

- 대법원은 설문과 유사한 사안에서 “서면에 의하여 증명되어야 할 법률관계를 둘러싸고 이미 소가 제기되어 있는 경우에는 그 소송에서 분쟁을 해결하면 되므로 그와 별도로 그 서면에 대한 진정 여부를 확인하는 소를 제기하는 것은 특별한 사정이 없는 한 확인의 이익이 없다¹⁵⁾.”고 판시한바 있으며,
- 반면에 判例는 “진부확인의 소가 제기된 후에 그 법률관계에 관련된 소가 제기된 경우에는 진부확인의 소의 확인이익이 소멸되지 않는다.”고 함.¹⁶⁾

3. 검토 및 설문(1)의 해결

- 설문의 경우 判例의 태도에 따르면 그 법률관계에 관련된 소가 진부확인의 소가 계속된 후에 제기되었으므로 확인의 이익이 있어 적법하나,
- 소송요건의 판단시기는 사실심 변론종결시(通說, 判例)이므로 각 소의 전후에 따라 다르게 판단하는 것은 다소 문제
- 서면에 의하여 증명되어야 할 법률관계를 둘러싸고 소송 중인 경우에는 제출되는 서면에 대해 진정성립을 그 소송에서 해결할 수 있으므로 별도의 진부확인의 소를 인정할 실익이 없을 것으로 판단.

III. 설문(2)의 해결 - 등기의 추정력

1. 문제점

- 법원 판결의 쟁점은, A가 적법한 대리인인지 여부'임.
- 위 사실이 진위불명 상태이므로, 그 불이익을 누구에게 끼쳐야 할지 증명책임이 문제되고, 특히 등기의 추정력이 법률상 추정인지 나아가 추정력의 범위가 判例의 태도와 관련하여 문제됨.

2. 객관적 증명책임의 의의 및 취지

- 요증사실이 진위불명일 때 일방이 받는 불이익, 법원이 판결을 회피할 수 없기 때문에 필요

15) 대판 2007. 6. 14. 2005다29290.29306 판결 참조

16) 대판 2007. 6. 14. 2005다29290.29306 판결 참조

3. 증명책임의 분배의 원칙

(1) 견해의 대립

- 증명책임의 분배원칙에 관하여 通說은 법률의 구조를 원칙으로 삼아 주로 법률의 전단에 해당하는 권리발생 요건사실은 원고가, 단서에 해당하는 저지, 멸각, 소멸사실인 항변사실은 피고가 증명책임을 부담한다고 봄. 그러나 최근에는 증거의 거리 및 위험영역이 누구의 지배하에 있는지 등을 고려하는 증거거리설 및 위험영역설 등이 대두되고 있음.

(2) 判例의 태도

- 대법원은 원칙적으로 通說과 마찬가지로 권리발생요건사실은 원고가 증명책임을 지고, 항변사실은 피고가 증명하지 못하면 그 사실이 없는 것으로 취급해야 한다고 하여 법률요건분류설을 취하고 있는 것으로 보이나, 최근에는 개연성 및 간접반증을 인정하는 판 시도 등장하고 있음.

(3) 검토 - 수정 법률요건 분류설

- 증거거리설, 위험영역설도 일응 타당한 측면이 있지만 객관적 판단기준을 담보한다는 면에서 법률요건분류설이 타당한 것으로 보이며 다만 의료사고, 공해소송 등 현대형 소송에서는 증거의 구조적 편재를 시정하기 위해 증거거리설 등을 고려하여도 좋을 것이라는 수정 법률요건분류설이 타당하다고 판단됨.
- 따라서 설문에서 ‘유권대리 행위’는 권리발생 요건사실로, 피고인 乙이 증명책임을 부담하는 것이 원칙임.

4. 등기의 추정력

(1) 문제점

- 법률요건분류설에 따르면 유권대리 행위는 피고 乙이 증명책임을 부담하나 그 확신을 주지 못했으므로 패소 가능.
- 단, 법률상의 추정으로 보아 증명책임이 전환되는지 문제됨.

(2) 判例의 태도

- 부동산 등기의 추정력을 인정한 명문의 규정이 없기 때문에 여기에 법률상 추정력을 인정할 것인가 문제되나, 대법원은 등기의 추정력을 법률상 추정으로 보고 있으며 나아가 추정의 범위는 등기부에 공시되는 소유권 취득원인 뿐만 아니라 그 취득과정의 적법성까지 추정하며, 계약이 대리인에 의하여 체결된 것일 때에는 대리권의 존재에 이르기까지 추정력이 미친다고 봄.

(2) 學說의 태도 및 검토

- 일부견해(이)는 증명책임의 전환을 인정하는 법률상 추정은 명문의 규정이 있는 경우에 인정하는 것이 타당하다는 점을 근거로 등기의 추정력을 사실상 추정으로 보고 있으나, 현행법상 등기에 공신력이 인정되지 않아 법률상 지위가 불안한 등기명의인을 보호하고

동산은 단순히 점유만으로 법률상 추정력이 인정되는 것(민법 제200조)과의 균형상 등기부에 법률상 추정을 인정해야 할 것임.

5. 법률상 추정의 효과 및 설문(2)의 해결

- (1) 법률상 추정이 이루어지는 경우 거증자는 전제사실만 증명해도 주요사실이 추정되므로 증명책임이 완화되나, 피고는 법률상 추정이 이루어진 경우 이를 복멸하기 위해서는 추정된 사실의 반대사실의 증거를 '본증'으로 증명해야 하며, 결국 주요사실이 진위불명일 때는 추정을 복멸하지 못하게 됨.
- (2) 설문의 경우
 - 사실상 추정으로 보는 견해에 따르면 甲의 청구가 인용될 수 있으나,
 - 법률상 추정설에 따르면 '적법한 대리행위'가 법률상 추정을 받으며 乙이 본증으로 반대사실을 증명하지 못한바 위 추정이 유지되어 결국 甲의 청구를 기각해야 할 것임.

[B-2]

I. 설문(1)의 해결 - 소송절차의 중단을 간과하고 선고한 판결의 효력

1. 문제점

- 판결의 적법·유효한지와 관련하여 소송절차의 중단여부 및 중단을 간과하고 선고한 판결의 효력과 관련하여 당사자의 지위가 당연히 상속인에게 승계되는지 문제됨.

2. 소송절차의 중단여부

- (1) 중단의 요건
 - ①사망시기가 소송계속 후이고, ②소송물인 권리의무가 상속의 대상이 될 것을 요하며, ③상속인이 존재하여야 하고, ④사망한 당사자 측에 소송대리인이 선임되어 있지 않아야 함.
- (2) 설문의 경우
 - 중단됨.

3. 당사자 지위의 당연승계 여부¹⁷⁾

- (1) 견해의 대립
 - 형식적 당사자개념의 불일치 등, 당연승계부정설
 - 포괄승계사유 등, 당연승계긍정설(通說)
- (2) 判例의 태도
 - 이당사자대립구조 유지, 당연승계긍정설

17) 당연승계여부는 오직 간과하고 선고한 판결이 위법한지 무효인지 여부에 대한 '이념적 배경'을 제공할 뿐입니다. 따라서 간단히 처리해 줄 문제이며 지나치게 강조하거나 그 결과를 오해하시면 안됨.

(3) 검토

- 당연승계긍정설 타당

4. 소송절차의 중단을 간과하고 선고한 판결의 효력

(1) 문제점

- 제233조 및 제247조 제1항의 반대해석

(2) 견해의 대립

- 무효설 : 당연승계부정설을 기초로 제247조 제1항의 반대해석상 위법하고 하자 있는 판결임이 명백하고, 대립당사자 구조가 파괴되어 있는 점은 제소당시에 이미 사망한 경우와 차이가 없고 이를 대리권의 흠결이 있는 경우와 동일시 할 수 없다는 점 및 절차기본권의 중대한 침해라는 점을 들어 이를 간과하고 내려진 판결은 무효라는 견해.
- 위법설 : 당연승계긍정설을 기초로 중단사유가 발생하였음에도 불구하고 이를 간과하고 진행한 끝에 판결이 선고되었다고 하여 당연무효는 아니며, 비록 당사자대립구조가 파괴되어 있으나 소제기당시 이미 당사자가 사망한 경우와는 동일하지 않으므로 위법한 판결일 뿐이며 대리권의 흠결에 준하여 그 판결이 확정전이면 상소, 확정 후이면 재심에 의한 취소사유일 뿐이고 또한 당사자가 이러한 판결에 추인하면 그 하자는 치유되는 것

(3) 判例의 태도

- 종래 判例는 위법설의 입장에서 상소를 인정한 것과 당연무효로 상고의 대상적격이 없어서 그에 대한 상고는 부적법하다는 것이 혼재하였으나 이후 전원합의체판결로 소송절차의 중단 중 변론을 기초로 한 판결에 소송에 관여할 수 있는 적법한 수계인의 권한을 배제한 결과가 되는 위법은 있으나 그 판결이 당연히 무효라고 할 수는 없고, 다만 대리인에 의해 적법하게 대리되지 않은 경우와 마찬가지로 보아 대리권 흠결을 이유로 상소 또는 재심에 의하여 취소를 구할 수 있을 뿐이라고 판시하여 위법설을 채택.

5. 검토 및 설문(1)의 해결

- 일단 대립당사자 구조는 발생한 것, 당연히 상속인과의 사이에서 소송승계가 이루어진다고 볼 것이므로 당사자 대립구조가 완전히 파괴되었다고 보기도 어려움. 따라서 대리권을 흠결한 경우와 달리 취급 할 필요가 없으므로 위법설이 타당하다고 판단되며 결국 항소심 판결은 당연무효는 아니며 위법한 판결임.

II. 설문(2)의 해결 - 독립당사자참가(제79조) 적법여부

1. 의의 및 취지

- 제79조 / 소송경제, 판결의 모순저축 방지

2. 요건(계, 이, 취, 병, 건)

- ①타인간의 소송이 계속중일 것, ②참가이유, ③참가취지, ④소의 병합요건을 갖출 것,

⑤일반 소송요건을 갖출 것을 요함.

- 설문과 관련해서는 다른 요건은 문제없어 보이나 특히 권리주장참가로서 허용될 수 있는 경우인지와 관련하여 ②참가이유가 문제되며, 만약 참가이유가 있다면 ③참가취지와 관련하여 편면참가가 허용될 수 있는 것인지가 문제됨.

3. 참가이유 - 권리주장참가

(1) 양립불가능성의 판단

1) 견해의 대립

- 學說의 일반적인 견해는 본소청구와 참가인의 청구가 주장 자체에서 양립되지 않는 관계이면 독립참가가 허용되어야 하며, 본안심리 결과와는 관계가 없다고 하여 설문의 경우 특히 자신이 실질적인 매수인이라고 주장하고 있으므로 주장 자체로 보아 양립불가능하기 때문에 참가사유를 긍정함.

2) 判例의 태도

- 대법원은 일반적인 부동산의 이중양도의 경우에는 양수인은 양도인에게 소유권이전등기 청구권만이 있고, 배타적인 물권이 없으므로 독립참가가 허용되지 않는다고 함. 즉, 양립이 가능한 채권에 기한 청구로써는 참가할 수 없다고 보는 것이다. 다만, 타인명의로 부동산을 매수하는 경우와 같이 명의상의 매수자와 사실상의 매수자 사이에 매수인의 지위가 논리상 양립할 수 없는 경우에는 참가를 허용함.

(2) 검토 및 설문의 경우

- 독립참가의 요건은 소송요건이므로 본안심리에 앞서 참가인의 주장 자체만으로 참가요건의 구비여부를 따져야 할 것이고 본안심리의 결과에 의하여 참가의 요건을 가릴 필요는 없을 것임.
- 원칙적으로 부동산의 이중양도는 제2매수인인 원고가 주장하는 소유권이전등기청구와 제1매수인인 참가인이 주장하는 소유권이전등기청구는 각기 다른 매매계약에 기한 것이고 민법상 채권자평등의 원칙으로 인해 주장 자체로 양립불가능하다고 판단하기 어려울 수 있으나 설문의 경우와 같이 자신만이 매수인이고 甲은 매수인이 아니라고 주장하는 것은 學說이나 判例의 입장 모두 주장자체로 보아 양립 불가능한 경우라 할 것이므로, 본소청구와 양립 불가능하여 적법하다 판단됨.¹⁸⁾

4. 참가취지 - 편면참가 허용여부

(1) 문제점

- 丁의 독립당사자참가가 권리주장참가로서 참가이유가 적법하다 하더라도 참가취지 또한 적법해야 참가자체가 적법. 설문과 관련해서는 丁이 甲에 대해서 자신에게 청구권이 있다는 적극적 확인을 구하지 않고 甲에게 이전등기청구권이 없다는 부존재확인청구를 하고 있는바 확인의 소의 대상적격은 큰 문제가 없어 보이나¹⁹⁾ 특히 확인의 이익과 관련

18) 충실한 검토가 필요한 부분입니다. 또한 만약 단순한 이중양도의 사안이라면 判例와 學說(부정설)에 따라 참가이유가 부적법하다 할 것이고 이 경우는 반드시 사해방지참가의 요건에 해당하는지를 검토해 주어야 합니다.

해 부적법한 것은 아닌지가 문제되고, 만약 부적법하다면 편면참가를 허용할 수 있는지가 문제됨.

(2) 이전등기청구권 부존재확인청구의 확인의 이익

- 확인의 소는 자기의 권리 또는 법적지위가 타인으로부터 부인당하거나 이와 양립하지 않는 주장을 당하게 되는 경우 등 ①법률상의 지위에 ②현존하는 불안이 있어야 하고 ③불안을 해소시킴에 있어서 확인판결을 받는 것 이외에 유효적절한 수단이 없을 것을 요함.
- 설문에서 丁은 甲에 대해서 자신에게 청구권이 존재한다는 적극적 확인의 소를 제기할 수 있음에도 불구하고 상대방에게 권리가 존재하지 아니한다는 소극적 확인의 소를 제기한바 결국 가장 유효적절한 수단이 아니므로 확인의 이익이 없어 부적법함.

(3) 편면참가의 허용여부

- 종래의 논의²⁰⁾ : 종래 學說은 제도를 용이하게 이용할 수 있도록 편면참가를 허용하는 입장과 명문의 규정에 충실하게 이를 부정하는 견해가 대립하였고, 종래 判例는 설문과 유사한 사안에서 참가인의 청구는 원고 및 피고 쌍방에 대하여 적극적으로 정립되어야 하는 것으로 판시함.
- 입법적 해결 : 현재 제79조 제1항은 제3자는 당사자의 양 쪽 또는 한 쪽을 상대방으로 하여 소를 제기하는 것을 허용하고 있는바 입법적으로 편면참가를 허용하였고 타당함.

5. 검토 및 설문(2)의 해결

- 설문의 경우 丁의 甲에 대한 이전등기청구권 부존재확인청구는 확인의 이익이 없어 부적법함. 따라서 참가취지는 편면참가의 형태가 될 것인바 개정법은 편면참가를 허용하고 있으므로 부정하는 견해는 입론의 여지가 적다고 할 것임.
- 따라서 설문과 같은 丙의 권리주장참가는 참가취지 또한 적법하다 할 것이다.

※마치며 - 2014년의 대비※

□ 주요논점 위주의 출제경향을 어느 정도 지속될 것으로 생각합니다.

- 각 특점 point의 정확한 정리 및 ‘이해한 것으로 보이는 답안’에 대한 준비가 필요합니다.
- key-word는 충실히 암기해야 하겠습니다.

□ 기본서 및 조문의 정독

- 불의타에 대한 두려움으로 무한정 양을 늘리는 것은 ‘모든 논점을 불의타’로 만드는 지름길입니다.
- 기본서의 꼼꼼한 정독과 조문의 충분한 이해가 필요할 듯합니다. 감사합니다.

19) 누락 주의하세요.

20) 입법적으로 해결하였으므로 ‘종래의 논의’로 실시하는 것이 좋습니다.